

RECURSO CÍVEL Nº 5060305-50.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: THAIS NASCIMENTO MAGALHAES (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SALÁRIO MATERNIDADE. STF. TEMA 72. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA UNIÃO. JULGAMENTO DO RE Nº 576.967. STF DECLAROU INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28, § 2º DA LEI Nº 8.212/91. DECISÃO QUE PRIVILEGIOU O ENTENDIMENTO DE QUE O SALÁRIO MATERNIDADE É BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO SE CONSTITUINDO EM SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com a consequente manutenção da sentença nos termos que fora prolatada. Sem custas. Condene a recorrente vencida em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2024.

5060305-50.2024.4.02.5101

510014363620 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5060305-50.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: THAIS NASCIMENTO MAGALHAES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por **THAIS NASCIMENTO MAGALHÃES**, em face da **União**, visando seja declarada a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a rubrica do salário-maternidade, bem como a repetição do indébito tributário de todos os valores retidos indevidamente pela requerida sobre o salário-maternidade e seus reflexos.

A sentença, (Evento 21) julgou **PROCEDENTE** o pedido para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o benefício do salário-maternidade, bem como restituir os valores recolhidos indevidamente sob este título, com atualização da Taxa Selic, observada a prescrição quinquenal.

Em sede recursal (Evento 25), a União pugna pela reforma da decisão a quo, argumentando, em síntese, que o salário-maternidade integra o salário-de-contribuição, possuindo natureza salarial e integra, consequentemente, a base de cálculo da contribuição previdenciária.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre salientar a sentença de que se recorre:

Trata-se de ação pelo procedimento do juizado especial cível ajuizada por THAÍS NASCIMENTO MAGALHÃES em face da UNIÃO FEDERAL-FAZENDA NACIONAL, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o salário-maternidade, bem como a restituição dos valores descontados a esse título.

É o sucinto relatório. Decido.

Nos termos das alegações da autora, ela "... teve deferido auxílio maternidade, sob o n.º 217.928.127-1, entre 16/12/2023 (DER) e 13/04/2024, conforme Declaração de Benefício anexa. Ocorre que a Autarquia Previdenciária Ré ainda descontou indevidamente monta referente a contribuição previdenciária do benefício Autoral. Conforme se observa na certidão de nascimento acostada aos autos, a filha da Demandante nasceu em 16/12/2023 (...)".

Ainda segundo a autora, deve ser aplicada por analogia o disposto no TEMA nº 72 do Egrégio STF, uma vez que "... foram descontados da Autora duas parcelas de R\$ 1.202,99 (dois mil duzentos e dois reais e noventa e nove reais), totalizando R\$ 2.405,98 (dois mil quatrocentos e cinco reais e noventa e oito centavos), dos quais devem ser ressarcidos pela Fazenda Nacional com todos consectários legais. A supracitada quantia com juros e correção monetária, compõe a monta de R\$ 2.517,60 (dois mil quinhentos e dezessete reais e sessenta centavos), conforme planilha anexa, realizada nos moldes dos manuais da Justiça Federal".

Assim sendo, no seu entender, "... resta claro o direito da parte autora ao indébito tributário, que deverá ser acrescido dos mesmos juros e correção monetária".

Por outro lado, a ré requer o reconhecimento da inaplicabilidade do Tema nº 72/RG à contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo da empregada e sustenta, em síntese, que "o art. 28, §2º e § 9º, "a", parte final, da Lei 8.212, de 1991, deve ser considerado inválido tão-somente para o fim de compreender que o salário-maternidade não é remuneração, logo não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador".

Examinando as alegações de ambas as partes, creio que assista razão à autora.

O mencionado TEMA nº 72 do Egrégio STF possui o seguinte teor:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO - MATERNIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL.

1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária "patronal" sobre o salário-maternidade.

2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário.

3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91.

4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos.

5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: "É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". Grifei

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por maioria de votos, apreciando o Tema 72 da repercussão geral, em dar provimento ao recurso extraordinário, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, §2º, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do seu § 9º, alínea a, em que se lê "salvo o salário-maternidade", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo

Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente), que negavam provimento ao recurso. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". (STF - PLENÁRIO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.967 PARANÁ RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO - 05/08/2020)

Partindo da premissa de que o Egrégio STF entendeu que não pode incidir contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade, com base na mesma "ratio decidendi", essa incidência também não é possível em relação à cota parte do empregado.

Isso porque, pela redação do item 3 do julgado acima destacado, depreende-se que que Supremo Tribunal Federal declarou, de forma ampla, a inconstitucionalidade "da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, §2º, da Lei nº 8.212/91".

Nesse sentido, não obstante a tese fixada se refira apenas a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade a cargo do empregador, o provimento ao recurso extraordinário abrange a declaração de inconstitucionalidade do § 2º do art. 28, o que exclui a verba salário-maternidade da condição de salário de contribuição para a incidência da contribuição social a cargo da empregada, em razão da sua natureza de benefício previdenciário.

A matéria foi objeto de enunciado de Súmula pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, "in verbis":

Súmula 49: "Em que pese o fato do recurso extraordinário 576.967/PR, que deu origem ao Tema 72, do Supremo Tribunal Federal, realmente versar sobre a contribuição previdenciária a cargo do empregador, houve a declaração de inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, §2º, da Lei nº 8.212/91, o que vale para empregados e empregadores, portanto, já que o fundamento dessa inconstitucionalidade é a natureza de benefício previdenciário do salário-maternidade, mesmo que se considere possua ele natureza salarial, como diz o Tema 739 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que tal incidência deve ser afastada por ser inconstitucional, também no caso da contribuição previdenciária a cargo do empregado."

Confirmam-se os seguintes julgados da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro em situações análogas a relatada no presente feito:

TRIBUTÁRIO. SEGURADO FACULTATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SALÁRIO MATERNIDADE. PEDIDO DE REPETIÇÃO. STF. TEMA 72. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA FAZENDA ALEGANDO QUE O JULGAMENTO DO STF TRATA APENAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO MATERNIDADE A CARGO DO EMPREGADOR E NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. JULGAMENTO DO RE Nº 576.967. STF DECLAROU INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28, § 2º DA LEI Nº 8.212/91. DECISÃO QUE privilegiou o entendimento de que o salário maternidade é benefício previdenciário não se constituindo em salário de contribuição para fins de dedução de contribuição à previdência social. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (8ª TR-RJ, RECURSO CÍVEL Nº 5066396-98.2020.4.02.5101/RJ, JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES, JULGADO EM 11/12/2020)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SALÁRIO MATERNIDADE. STF. TEMA 72. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA UNIÃO. JULGAMENTO DO RE Nº 576.967. STF DECLAROU INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28, § 2º DA LEI Nº 8.212/91. DECISÃO QUE PRIVILEGIOU O ENTENDIMENTO DE QUE O SALÁRIO MATERNIDADE É BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO SE CONSTITUINDO EM SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (8ª TR-RJ, RECURSO CÍVEL Nº 5012016-69.2023.4.02.5118/RJ, RELATOR: Juiz Federal LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA, JULGADO EM 30/07/2024)

Por fim, em que pese o tema em questão - incidência de contribuição previdenciária da empregada sobre o salário-maternidade - esteja pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 1274), não houve determinação de suspensão dos processos que versam sobre a matéria, sendo certo que a pendência do julgamento pela Corte Suprema não impede a prolação de sentença no presente caso, consoante o art. 1.035, §5º, do CPC.

Uma vez demonstrada que a parte autora realmente foi descontada a título de contribuição previdenciária sobre o recebimento de seu salário maternidade, é plenamente cabível a restituição dos valores descontados, acrescidos da Taxa Selic desde a data dos descontos.

Diante de todo exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para **DECLARAR** a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade e **CONDENAR** a ré à restituição à parte autora dos valores indevidamente recolhidos, corrigidos pela taxa SELIC acumulada (art. 3º, EC 113/21).

O pagamento deverá se dar na forma do art. 17 da Lei nº 10.259/2001 e do Enunciado nº 52 das Turmas Recursais da Justiça Federal do Rio de Janeiro, obedecido ao teto dos JEFs, conforme dispõe o Enunciado 15 do FONAJEF.

Eventual pagamento administrativo da restituição do tributo objeto da presente condenação poderá ser abatido do montante a executar, devendo ser demonstrado cabalmente pela parte ré, no prazo de cumprimento de sentença, acima assinalado.

Sem custas e sem honorários no teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Em havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal, remetendo-se posteriormente os autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Oportunamente, dê-se baixa e archive-se.

Intimem-se.

O salário-maternidade encontra previsão legal na Lei nº 8.213/91, em seu artigo 71, sendo uma prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade, possuindo, caráter de benefício previdenciário.

O que diz a Constituição Federal sobre o financiamento da seguridade social:

"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (Vide EC 20/1998)

I — do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação da EC 20/1998.

II — do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social; (Redação da EC 103/2019)."

Sobre ser o salário maternidade salário de contribuição, a Lei nº 8.212/91 que:

"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

...

§ 2º O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição. Grifei

...

§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:

a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade;"

Pois bem.

Eis a decisão em repercussão geral pelo STF que teve como tema de fundo a contribuição previdenciária a cargo do empregador incidente sobre o salário maternidade como salário de contribuição:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO - MATERNIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL.

1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária "patronal" sobre o salário-maternidade.

2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário.

3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo

constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91.

4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos.

5. Diante do exposto, **dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: "É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade"**. Grifei

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por maioria de votos, apreciando o Tema 72 da repercussão geral, em dar provimento ao recurso extraordinário, para **declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, §2º, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do seu § 9º, alínea a, em que se lê "salvo o salário-maternidade"**, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente), que negavam provimento ao recurso. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". (STF - PLENÁRIO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.967 PARANÁ RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO - 05/08/2020)

Da leitura atenta da referida decisão se extrai que o STF declarou, de forma ampla, a inconstitucionalidade "**da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, §2º, da Lei nº 8.212/91.**", isto é, a despeito de mencionar na tese fixada apenas a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária à cargo do empregador, sobre o salário maternidade, o provimento ao recurso extraordinário abrange a declaração de inconstitucionalidade do § 2º do art. 28, excluindo, na verdade, a verba salário maternidade da condição de salário de contribuição para a incidência da contribuição social.

Desse modo, outra conclusão não há senão a de que esse julgado privilegiou o entendimento de que o salário maternidade é benefício previdenciário não se constituindo em salário de contribuição para fins de dedução de contribuição à previdência social.

Nesse cenário, não merece reparo a sentença que condenou a Fazenda Nacional a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o benefício do salário maternidade, que deverão ser corrigidos exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos da Lei n. 9.250/95 (art. 39, §4º).

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**, com a consequente manutenção da sentença nos termos que fora prolatada. Sem custas. Condeno a recorrente vencida em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.